

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3447/2531

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด หล่มสัก  
นาย บุญช่วย ชู รักษา

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 4, มาตรา 13, มาตรา 89

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ. 2518 ได้วิเคราะห์ศัพท์คำว่า "ขาย" หมายความว่าความรวมถึงจำหน่าย จ่าย แจก แลก เปลี่ยน ส่งมอบ หรือมีไว้เพื่อขาย ฉะนั้นการขายหรือมีไว้เพื่อขายตามนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้จึงเป็นความผิดอย่างเดียวกัน เมื่อปรากฏว่าจำเลยมีแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์อันเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทไว้เพื่อขายจำนวน 5 เม็ดและจำเลยขายไป 4 เม็ดยังเหลืออยู่ที่ตัวจำเลยอีก 1 เม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์จำนวน 5 เม็ดดังกล่าว จึงเป็นจำนวนเดียวกันกับที่จำเลยขายและมีไว้ในครอบครองเพื่อขายในเวลาเดียวกันและต่อเนื่องกัน การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวคือการขายนั่นเอง หากใช่เป็นการมีไว้ในครอบครองเพื่อขายอีกกระทงหนึ่งไม่

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ซึ่งเป็นเกลือของแอมเฟตามีนอันเป็นวัตถุออกฤทธิ์จำนวน 5 เม็ด น้ำหนัก 1.15 กรัมไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วจำเลยขายให้แก่ผู้ซื้อจำนวน 4 เม็ด เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ 1 เม็ด ที่จำเลยมีไว้และเหลือจากการขายธนบัตรฉบับละ 20 บาท จำนวน 1 ฉบับ ฉบับละ 10 บาท จำนวน 4 ฉบับ ที่จำเลยได้จากการขายวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวเป็นเจ้าของขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ. 2518 มาตรา 4, 6, 13, 89, 116 ริบแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ของกลางและคืนธนบัตรของกลางที่ใช้ทำการล่อซื้อแก่เจ้าของ

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ประกอบด้วยมาตรา 89 รวม 2 กระทง ให้ริบกระหนาบโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกจำเลยกระทงละ 5 ปีรวมจำคุก 10 ปี คำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดีเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาล มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 5 ปี ริบวัตถุออกฤทธิ์ของกลางให้แก่กระทรวงสาธารณสุข คืนธนบัตรของกลางให้แก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

## จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อ 6 (ข) ว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน พิจารณาแล้วพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ได้บัญญัติห้ามเฉพาะการผลิตขาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 เท่านั้น ว่าเป็นความผิดและมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 89 และในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้วิเคราะห์ศัพท์คำว่า "ขาย" ว่ามีความรวมถึงจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ส่งมอบ หรือมีไว้เพื่อขายฉะนั้นการขายหรือมีไว้เพื่อขายตามนัยแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเป็นความผิดอย่างเดียวกัน คดีนี้ปรากฏว่าจำเลยมีแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์อันเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทไว้เพื่อขายจำนวน 5 เม็ด และจำเลยได้ขายแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ดังกล่าวให้แก่สืบตำรวจโทนครไปจำนวน 4 เม็ด ยังเหลืออยู่ที่ตัวจำเลย 1 เม็ด แอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์จำนวน 4 เม็ดที่จำเลยขายให้แก่สืบตำรวจโทนครกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค้นได้จากจำเลยอีก 1 เม็ด รวมทั้งสิ้นเป็น 5 เม็ด จึงเป็นแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์จำนวนเดียวกับที่จำเลยขายและมีไว้ในครอบครองเพื่อขายในเวลาเดียวกันและต่อเนื่องกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวคือการขายนั่นเอง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยมีแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ไว้ในครอบครองเพื่อขายอีกกระทงหนึ่งจึงไม่ถูกต้อง ฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานขายวัตถุออกฤทธิ์ชนิดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13, 89 เพียงกระทงเดียว ให้จำคุก 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

หลักในการวินิจฉัยว่าเป็นความผิดกรรมเดียวกันหรือเป็นความผิดต่างกรรมกันนั้น ให้พิจารณาจากเจตนาของผู้กระทำความผิดเป็นสำคัญว่าเป็นเจตนาเดียวหรือหลายเจตนาหรือเจตนาต่างกันจะนำหลักต่างกรรมต่างวาระมาเป็นหลักในการวินิจฉัยไม่ได้ นอกจากนั้นบทหรือฐานความผิดก็เป็นส่วนประกอบในการช่วยวินิจฉัยด้วยความผิดต่างฐานกันในบางกรณีก็ถือว่าเป็นความผิดต่างกรรมกันหากผู้กระทำมีเจตนาต่างกัน เช่น มีเฮโรอีนและฝิ่นไว้ในความครอบครอง หรือความผิดในเรื่องเดียวกันอาจเป็นความผิดกรรมเดียวกันได้หากผู้กระทำมีเจตนาเดียวกัน เช่น มีฝิ่นและมุลฝิ่นไว้ในความครอบครอง เป็นต้น ความผิดฐานมีไว้เพื่อขายและขายแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์อันเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเป็นความผิดอย่างเดียวกันเพราะคำว่า "ขาย" ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา

4 ให้รวมถึงการมีไว้เพื่อขายด้วย ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกอยู่ที่นี่ ศาลฎีกาเห็นว่าแม้จำเลยจะขายแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ไป 4 เม็ด และยังมีเหลือที่ตัวจำเลยอีก 1 เม็ด ความผิดฐานมีไว้เพื่อขายและขายแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ดังกล่าวก็เป็นความผิดกรรมเดียวกัน มิใช่ความผิดต่างกรรมกัน เรื่องทำนองนี้ ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ ฐานมีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ซึ่งเป็นความผิดในมาตราเดียวกัน (ดูพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66) หลายเรื่องโดยวางหลักว่า หากยาเสพติดให้โทษที่จำเลยมีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายกับยาเสพติดให้โทษที่จำหน่ายเป็นยาเสพติดจำนวนเดียวกัน ความผิดดังกล่าวจะเป็นความผิดกรรมเดียวกันเสมอ เช่น จำเลยมียาเสพติดให้โทษชนิดเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและได้จำหน่ายยาเสพติดให้โทษดังกล่าวให้แก่ผู้มีชื่ออีกด้วย การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวกันเพราะที่จำเลยมีเฮโรอีนของกลางไว้โดยเจตนาจะจำหน่ายและเฮโรอีนที่จำหน่ายก็คือเฮโรอีนของกลางที่จำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายนั่นเองมิใช่เอาเฮโรอีนอื่นมาจำหน่าย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2085/2517) หรือโจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเฮโรอีน 2 หลอดไว้เพื่อจำหน่าย แล้วจำเลยขายเฮโรอีน 2 หลอดนั้นให้กับบุคคลอื่น ดังนั้นเฮโรอีนที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายกับเฮโรอีนที่จำเลยจำหน่ายให้กับบุคคลอื่นนั้นคือเฮโรอีนจำนวนเดียวกันนั่นเอง ไม่มีเฮโรอีนจำนวนอื่นที่จำเลยอีกเลย การกระทำของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นความผิดกรรมเดียว หากใช้ความผิดสองกรรมต่างหากกันไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2061/2521 นอกจากนี้คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2065/2521, 2362/2521, 12/2522, 598/2522, 1074/2522, 1908/2522, 820/2523, 1331/2523, 2127/2523, 1550/2527) นอกจากนี้แม้จะเป็นความผิดคนละบทมาตรานี้ แต่หากข้อเท็จจริงฟังได้ว่ายาเสพติดนั้นเป็นจำนวนเดียวกันก็เป็นความผิดกรรมเดียวกันได้ เช่น ปลุกักัญชาและมีต้นกัญชาที่ปลูกไว้ในความครอบครอง ไม่มีกัญชาอื่นอีกเป็นความผิดกรรมเดียว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1313/2523) หรือปลุกักัญชาแล้วมีกัญชาที่ปลูกไว้เพื่อจำหน่าย เป็นผลจากการปลูกหรือผลิตกัญชานั้นเอง เป็นความผิดกรรมเดียวมิใช่ฐานผลิตกัญชากรรมหนึ่งและมีกัญชาเพื่อจำหน่ายอีกกรรมหนึ่ง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 65/2524 และดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2654/2517, 756/2527, และ 2742/2527) ในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3324/2522 วินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ไว้ในครอบครอง 6 เม็ด และขายแก่ผู้มีชื่อไป หมายความว่าชัดเจนว่าจำเลยขายไปหมด เป็นความผิดกรรมเดียว ข้อที่ว่าจำเลยจำหน่าย 1 เม็ดเหลือ 5 เม็ดไม่ได้กล่าวในฟ้อง ซึ่งแนวคำวินิจฉัยดังกล่าวของศาลฎีกาน่าจะถูกต้องแล้วเพราะเป็นเรื่องที่ผู้กระทำผิดมีเจตนาเดียว จากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวข้างต้นทำให้เข้าใจไปได้ว่าหากผู้กระทำผิดจำหน่ายเฮโรอีนหรือแอมเฟตามีนไม่หมด ยังเหลืออยู่บางส่วน ความผิดฐานมีเฮโรอีนหรือแอมเฟตามีนไว้เพื่อจำหน่ายหรือขายและจำหน่ายหรือขายย่อมเป็นความผิดต่างกรรมกันได้ ซึ่งเรื่องนี้เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2042/2522 วินิจฉัยว่า มีเฮโรอีนเพื่อจำหน่าย 4 หลอด จำหน่ายไป 1 หลอด จับจำเลยได้พร้อมด้วยเฮโรอีนที่เหลือ 3 หลอดกับเงินที่ล่อซื้อ ความผิดฐานมีเฮโรอีนเพื่อจำหน่าย 4 หลอดกับจำหน่ายเฮโรอีน 1 หลอดเป็นต่างกรรมกันแม้เฮโรอีนจำนวน 1 หลอดที่จำเลยจำหน่ายไปจะเป็นเฮโรอีนจำนวนเดียวกันกับเฮโรอีน 4 หลอดที่จำเลยมีไว้เพื่อจำหน่าย การกระทำของจำเลยก็แยกได้เป็นสองกรรมต่างหากจากกัน (นอกจากนี้ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1198/2519 (ประชุมใหญ่) และ 1997/2521 ซึ่งวินิจฉัยทำนองเดียวกัน) และมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1331/2516 วินิจฉัยว่าเสพเฮโรอีนและมีเฮโรอีนที่เหลือจากการเสพไว้ในครอบครองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน แต่อย่างไรก็ดีเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 760/2520 วินิจฉัยว่า มีเฮโรอีนไว้เพื่อจำหน่าย 10 ถึง เป็นกรรมเดียวกับจำหน่ายเฮโรอีนที่มีไว้ไป 1 ถุง (อ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2045/2517 ซึ่งวินิจฉัยทำนองเดียวกัน) มีปัญหาว่าแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

ทั้งสองแนวที่แตกต่างกันดังกล่าว แนวใดน่าจะถูกต้อง เมื่อพิจารณาถึงหลักที่กล่าวข้างต้นที่ว่า การวินิจฉัยว่าเป็นความผิดกรรมเดียวกันหรือเป็นความผิดต่างกรรมกันนั้น ให้พิจารณาจากเจตนาของผู้กระทำความผิดเป็นสำคัญแล้วจะเห็นว่า กรณีของการมียาเสพติดให้โทษไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายยาเสพติดจำนวนเดียวกันแต่จำหน่ายไม่หมดเช่นนี้ เห็นได้ว่าการมีไว้เพื่อจำหน่ายกับการจำหน่ายเป็นเจตนาเดียวกันนั่นเอง เพราะยาเสพติดที่มีไว้เพื่อจำหน่ายกับที่จำหน่ายเป็นจำนวนเดียวกัน การมียาเสพติดไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายแม้จะเป็นความผิดสำเร็จแล้วอยู่ในตัว แต่ก็หาได้หมายความว่า การนำยาเสพติดจำนวนนั้นมาจำหน่าย ผู้กระทำได้เกิดเจตนาขึ้นมาใหม่ไม่ ทั้งนี้ เพราะเจตนาการขายไปก็คงเป็นเจตนาเดียวกันกับเจตนาที่มีไว้ในความครอบครองเพื่อขายต่อเนื่องกันมานั่นเองเมื่อพิจารณาได้ดังนี้แล้ว การกระทำความดังกล่าวย่อมเป็นความผิดกรรมเดียวกัน หาใช่ความผิดต่างกรรมกันไม่ ฉะนั้น ไม่ว่าจะ เป็นกรณีจำหน่ายยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายหมดไปหรือจำหน่ายไม่หมดผลก็น่าจะเป็นอย่างเดียวกัน นั่นคือความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายยาเสพติดโดยผิดกฎหมาย ย่อมเป็นความผิดกรรมเดียวกันทั้งสองกรณี ผู้บันทึกจึงมีความเห็นว่าที่ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ในคดีที่บันทึกอยู่นี้ชอบแล้ว

ปริญญาดิษฐ์